

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

[예상][4.03-1]특별수권사항의 의의, 구체적 범위, 특별수권없는 대리의 효력

《【문제4.3-1】특별수권사항에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제4.3의 물음1> 특별수권사항의 의의, 구체적 범위, 특별수권없는 대리의 효력

I. 소송대리권 범위의 법정주의와 특별수권사항의 의의

1. 소송대리권 범위의 법정주의 [민사소송법 제90조 제1항]

- 소송법상 소송대리인의 권한 범위를 전적으로 사적 계약에만 의존하게 하면 소송 상대방이 예상치 못한 불이익을 입기 쉽고, 소송절차의 확실적·안정적인 진행을 해치게 된다. 따라서 우리 민사소송법은 소송대리인의 권한 범위를 법률로 획일화하여 직접 규정하는 법정주의를 채택하고 있다.

2. 특별수권사항의 의의

- 소송대리인 은 위임받은 소송에 대하여 소의 제기나 화해 등 일체의 소송행위를 할 수 있는 일반적 대리권을 가진다. 다만, 소송물의 처분이나 소송의 종료 등 본인의 실체적 권리관계에 심대한 영향을 미치는 특정 소송행위에 대해서는 본인의 명시적이고 개별적인 권한 수여를 요구하는데, 이를 특별수권사항이라 한다.

II. 구체적 특별수권사항의 범위

1. 소송의 개시·종결 등에 관한 사항 [민소법 제90조 제2항 제1호·제2호]

- 본인의 적극적인 의사 결정 및 처분의사가 필수적인 항목들로서, 반소의 제기, 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 독립당사자참가소송탈퇴를 하려면 특별수권을 별도로 받아야 한다.

2. 대리인 선임 및 상소 등에 관한 사항 [민소법 제90조 제2항 제3호·제4호]

- 소송대리인이 자신이 가진 대리권에 기초하여 다른 대리인을 선임하는 복대리인의 선임, 심급을 이동시키거나 소송을 종료시키는 상소의 제기 또는 취하, 대리인의 선임을 하는 경우에도 반드시 특별수권이 존재하여야 한다.

III. 특별수권 없는 대리행위의 효력 및 본인의 추인 가부

1. 특별수권 없는 대리행위의 효력

(1) 원칙

- 특별수권이 결여된 채 이루어진 소송대리인의 소송행위는 소송법상 무권대리행위가 되어 원칙적으로 무효이다.

(2) 간과 판결 효과

- 다만, 이러한 하자를 법원이 간과하고 본안판결을 선고한 경우, 판결이 확정되기 전에는 상소(항소 및 상고)를 제기하여 판결을 취소할 수 있고 판결이 이미 확정되었다면 재심의 소를 제기하여 구제받을 수 있다.

2. 본인의 추인 가부

(1) 추인의 소급효와 요건

- 민사소송법 제97조가 제60조를 준용하여 무권대리인의 소송행위라도 소송경제 및 당사자의 이익을 위해 본인이 사후에 추인하는 것을 허용한다. 본인의 적법한 추인이 있으면 무권대리 소송행위는 행해진 시점으로 소급하여 대리권이 있었던 것과 동일하게 유효해진다.

(2) 추인의 방식 및 시기적 한계

- 추인의 방식은 반드시 서면이나 명시적 언동으로만 해야 하는 것은 아니며, 무권대리 소송행위의 결과를 묵묵히 받아들이는 등의 묵시적 방식으로도 가능하다. 추인을 할 수 있는 시기는 소송절차의 안정을 지나치게 해치지 않는 한 판결이 확정되기 전까지이며, 사실심은 물론 상고심에서도 자유롭게 추인할 수 있다.

IV. 결론

- 소송대리권 범위의 법정주의 체제 하에서 특별수권사항은 대리인의 독단적인 권리 처분 행위로부터 소송당사자 본인의 실질적 이익을 두텁게 보호하기 위한 법률상의 안전망이다. 따라서 법원은 소송절차의 정당성과 사법 신뢰를 확보하기 위해 대리권의 존부 및 특별수권 구비 여부를 직권으로 엄격하게 조사하여야 한다. 다만, 절차적 흠결이 발생한 대리행위에 대해서는 사후 추인 제도를 유연하게 조화시킴으로써 불필요한 소송 지연을 막고 사법자치를 조화롭게 실현하여야 할 것이다.